

1527086-32.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1527086-32.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1527086-32.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL FERREIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

RAFAEL FERREIRA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, "caput", do Código Penal, porque, segundo apurado, no dia 06 de novembro 2021, por volta das 11h37min, na Avenida do Estado, nesta cidade e comarca da capital, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, o aparelho de telefone celular, marca Samsung A71, avaliado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente à vítima J. P. de A.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado, notificado e apresentou resposta à acusação.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos a vítima, dois policiais e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações, o Ministério Público buscou a procedência da ação nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa requereu absolvição do réu pelo crime de roubo, alegando que o réu exibiu o simulacro de arma de fogo para a vítima, com o intuito de se defender e não para ameaçá-lo. Ressaltou, ainda que não houve eventual aditamento da denúncia para eventual capitulação ao art. 157, §1º do Código Penal o que impediria a condenação por este crime, em razão de não haver correlação da acusação com a sentença.

Subsidiariamente, em caso de eventual condenação pugnou pela desclassificação do

crime de roubo para o crime de furto, já que não houve violência ou grave ameaça à pessoa no momento da subtração, e ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, o não reconhecimento da agravante do art 61, inciso II, alínea "j", a aplicação da atenuante prevista no art 65, III, "d" do Código Penal, fixação de regime semiaberto para o cumprimento de pena, com aplicação do disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, a revogação da prisão preventiva bem como a concessão de liberdade provisória.

Os autos vieram então conclusos para sentença, ocasião em que esta magistrada, considerando sobretudo a narrativa da vítima, nos termos do disposto no art. 384, do Código de Processo Penal, determinou abertura da vistas dos autos ao Ministério Público, para eventual aditamento da denúncia. (fls. 152).

A Defesa, ao tomar conhecimento de tal decisão, pugnou pela reconsideração do despacho que determinou a abertura de vistas dos autos ao Ministério Público, o não aditamento de denuncia ou ainda vista para se manifestar sobre o eventual aditamento.

O Ministério Público ofertou manifestação pugnando pela adequação da capitulação do fato imputado ao réu na denúncia para requerer sua condenação como incurso no art. 157§1º, do Código Penal, sob o fundamento de que a vítima ouvida em audiência de instrução relatou que o réu a ameaçou com o emprego de um simulacro de arma de fogo, após a subtração.

Instada a se manifestar, a Defesa, reiterou a manifestação anterior e pugnou pela rejeição do aditamento da denúncia.

O aditamento foi recebido a fls. 184, ocasião em que designou-se novo interrogatório do acusado que foi realizado a fls. 195/198.

Encerrada a instrução criminal o Ministério Público oralmente pugnou, em sua pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia e de seu aditamento.

A Defesa por sua vez, arguiu nulidade da decisão de fls. 165/169, alegando que o Ministério Público já havia reiterado os termos da denúncia e que houve assim violação ao sistema acusatório, ao devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a paridade de armas, com a consequente nulidade de todos os atos processuais praticados a partir de fls. 152.

No mérito, propriamente dito, pugnou novamente pela a desclassificação do crime de roubo para furto, alegando que o réu exibiu o simulacro de arma de fogo para a vítima, com o intuito de se defender e não para ameaça-lo e assim fazer com que o bem lhe fosse entregue, e ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, o não reconhecimento da agravante do art 61, inciso II, alínea "j", a aplicação da atenuante prevista no art 65, III, "d" do Código Penal, fixação de regime semiaberto para o cumprimento de pena, com aplicação do disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, a revogação da prisão preventiva bem como a concessão de liberdade provisória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há que se falar em nulidade do despacho de fls. 152, que foi prolatado nos exatos termos do que dispõe o art. 384, do Código de Processo Penal, que nestes termos prevê que: "Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, no prazo de 05 dias". (...).

Diante disso o juízo, sem interferir na acusação encaminhou os autos ao Ministério Público, que apenas procedeu a adequação da capitulação dos fatos narrados na denúncia, inserindo na acusação o disposto no §1º, do art. 157.

Veja-se que ao contrário do alegado pela Defesa, os autos foram a elas encaminhados (fls. 164/169), ocasião em que requereu a reconsideração da decisão ou ainda a abstenção do Ministério Público.

Em seguida o Ministério Público se manifestou e promoveu o aditamento da denúncia (fls. 175/179) e novamente foi aberta vista a Defesa, nos exatos termos do que dispõe o §2º, do art. 384, do CPP.

E somente após a devida manifestação da Defesa, o aditamento foi recebido.

Veja-se que neste ponto, apesar de não haver determinação legal expressa nesse

sentido, esta magistrada, justamente para garantir a ampla defesa designou novo interrogatório do acusado, que foi novamente ouvido, após se entrevistar com a Defesa.

Desse modo, seja diante da legalidade da decisão de fls.152, ou ainda pela preclusão consumativa de eventual interposição de eventual recurso por parte da Defesa e tendo sido garantido ao réu a ampla Defesa e o contraditório, inclusive com novo interrogatório, afasta-se a preliminar de nulidade requerida pela Defesa e passa-se então a análise do mérito.

A materialidade delitativa do roubo é irrefutável, diante do auto de prisão em flagrante, auto de exibição/apreensão do simulacro de arma de fogo, fotografia de fls. 30 e laudo pericial de fls. 138/140, auto de avaliação do telefone subtraído, boletim de ocorrência de fls. 31/35; relatório final da autoridade policial, tudo aliado a firme e segura prova oral coligida durante o crivo do contraditório.

A autoria também é inconteste.

Ouvida em juízo, a vítima J.P. de A., após fornecer as características do roubador, e ser colocado na presença de algumas pessoas, reconheceu o réu como autor do delito. Ao ser indagado sobre os fatos, relatou que estava no interior de seu veículo, parado no semáforo na Avenida do Estado, quando um indivíduo, fingindo ser vendedor ambulante de cliques de cabelo, chegou na janela do seu veículo e, jogou um prendedor dentro de carro e assim conseguiu distraí-lo e puxou o celular que estava dentro do veículo, quebrando assim o vidro de seu automóvel.

Em razão do susto e diante do ocorrido, tentou avançar com o veículo na direção do réu, e ao desembarcar do carro e ir em direção do acusado, foi por ele surpreendido com ameaça, já que o réu lhe apontou um revólver, que posteriormente soube se tratar de um simulacro de arma de fogo.

Temendo por um mal maior, voltou para seu veículo e entrou em um estacionamento onde acionou a polícia e após verificar a localização de sua aparelho celular, em razão do sistema de rastreador nele existente, informou aos policiais a localização do réu.

Logo após, foi avisado pelos policiais que um indivíduo com as mesmas características por ele mencionadas foi detido próximo do local por ele indicado, portando um simulacro de arma de fogo, mas que seu celular no entanto, não fora encontrado. Os policiais afirmaram que este indivíduo que seria encaminhado levado à Delegacia de Polícia e solicitaram que ele também comparecesse ao distrito policial, para eventual reconhecimento do roubador.

Diante disso ingressou em seu veículo e rumou para a Delegacia apontada pelos policiais e no trajeto, cruzou com a viatura da polícia onde o réu estava detido e de imediato, o reconheceu com sendo o autor da subtração de seu aparelho celular o que fez novamente na Delegacia de Polícia, onde o réu lhe foi apresentado juntamente com outros indivíduos. Por fim, afirmou que seu aparelho celular valia aproximadamente R\$ 1.700,00 reais e apesar de possuir sistema de rastreador não foi localizado.

No mesmo sentido das alegações da vítima, Rodrigo Pinheiro Reis da Silva e Patrício Luiz Ribeiro, os dois policiais militares arrolados na denúncia ao prestarem depoimento judicial, após, serem devidamente advertidos das consequências do falso testemunho, relataram que efetuavam patrulhamento ostensivo de rotina, nas proximidades da Avenida do Estado, e foram acionados via COPOM, para atendimento de uma ocorrência de roubo de celular.

A vítima teria acionado a polícia via 190 e informado as características físicas e de vestimentas do indivíduo, bem como o provável local que seu aparelho celular estava. Diante de tais fatos, se dirigiram ao local mencionado e encontraram com o réu que ao ser abordado portava um simulacro de arma de fogo. Enquanto faziam a abordagem do réu a vítima, compareceu ao local indicado pelo rastreador de seu aparelho celular e de imediato reconheceu o acusado. Diante dos fatos, conduziram todos envolvidos até o Distrito Policial.

O réu ao ser ouvido em sede policial, permaneceu em silêncio.

Em juízo, nas duas oportunidades em que foi ouvido, ou seja, antes e depois do aditamento da denúncia, confirmou que realmente, ao visualizar a vítima parado com seu veículo em razão do trânsito e do semáforo e com os vidros do automóvel

abertos, subtraiu o aparelho celular que estava no painel e fugiu.

Disse que somente apontou o simulacro de arma de fogo contra a vítima pois ele teria avançado com o carro em sua direção e que antes da polícia prende-lo, conseguiu repassar o celular a outra pessoa.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas a condenação pelo crime de roubo é medida que se impõe.

Com efeito, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, já que a vítima, foi firme em relatar que após a subtração de seu aparelho celular o réu lhe apontou uma arma de fogo, que posteriormente soube se tratar de uma réplica e assim garantiu a posse do aparelho celular que sequer foi recuperado.

Releva notar, neste passo, que a palavra da vítima deve merecer crédito, porquanto não teria ela proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. O único interesse dela é, pois, apontar o verdadeiro culpado.

Aliás, esse entendimento é reiterado na jurisprudência: JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97.

Lembra-se, aqui, trecho da lição do clássico NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA, que espanca qualquer dúvida a respeito de eventual suspeita da palavra do ofendido: "A animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido, nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque tu, como ofendido, tem ódio contra ele -, é uma verdadeira e flagrante contradição; é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui" (cf. tradução brasileira, págs. 409-10).

Não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é, em regra, dependente de clandestinidade. Não se pratica roubo às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas. Por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto e roubo não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

Dessa forma, restando plenamente comprovado o emprego de grave ameaça, perpetrado pelo réu contra a vítima, para garantir a detenção da coisa, nos exatos termos do que prevê a acusação, nos termos do aditamento ofertado a fls.175/179.

Caracterizada, portanto, a infração penal de roubo simples, passo a dosimetria da pena.

O réu é reincidente, já tendo sido condenado definitivamente perante a 2ª Vara Criminal Central, autos nº 0013160-74.2016.8.26.0635, (fls. 41), o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Se não bastasse isso, já foi condenado definitivamente nos autos nº 0013220-32.2011.8.26.0050, 0053642-78.2013.8.26.0050, fatos estes que serão tido como maus antecedentes. Assim sendo, a pena base será aumentada em 1/5, já que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, perfazendo assim o total de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Não há que se falar em desconsideração das condenações acima apontadas apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, de fato, se por um lado elas não podem mais serem consideradas como agravantes em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de considera-las como maus antecedentes, já que demonstram a personalidade criminoso do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

STJ- "condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser

valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes" (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, "não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência" (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos Veloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

"Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Na segunda fase a pena deve ser aumentada em mais 1/5, e ser fixada em 05 anos, 09 meses e 03 dias de reclusão e 14 dias-multa, considerando a presença da agravante da reincidência, acima apontada, bem como a prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, já que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020.

Neste ponto, em que pese as alegações da defesa, e respeitadas posições em contrário, para esta Magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

"Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: "(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se

valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias." (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020 - "O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença", escreveu o magistrado em seu voto. "De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

"O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

"Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - "(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o

tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública" (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020).

TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP - Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 -Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020). Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021. Des. Fátima Gomes- 9ª Câmara: "Com efeito, na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, encontra-se previsão para a agravação da pena diante de circunstâncias que representem o aproveitamento por quem realiza o crime da existência de uma situação de perigo comum. Cabe notar não ser necessário que o sujeito crie a situação de perigo, mas que apenas a aproveite. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.

Na situação especial, o apelante aproveitou-se de acontecimentos de especial relevo para a vida da população. O acontecimento e seus efeitos maléficos devem, obrigatoriamente, ser conhecidos por quem deles conscientemente aproveita-se. Nesse sentido: "Essa circunstância implica maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso se revela mais provável. É necessário que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevalecer-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua impunidade." (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal:

Jurisprudência, Conexões Lógicas com os Vários Ramos do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 335).

Assim, referida agravante tem natureza objetiva, estampada no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e, diante da notória calamidade pública gerada pela pandemia do vírus covid-19, mostra-se absolutamente desarrazoada a pretensão defensiva de afastá-la.

Não há que se falar em confissão já que como muito bem ponderado pela Defesa, o réu confessou apenas a subtração do aparelho celular, mas em todo momento em que foi ouvido negou ter ameaçado a vítima, afirmando que somente fez uso do simulacro de arma de fogo, que trazia consigo pois temeu ser atingido pela vítima.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Considerando que não há nos autos provas da condição econômica do acusado, fixa-se o dia multa no mínimo legal estabelecido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu como incurso nas sanções do art. 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 05 anos, 09 meses e 03 dias, e 14 dias-multa, no mínimo legal.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, diante da reincidência e dos maus antecedentes atestados nos autos, como fulcro no que dispõe o art. 33, 2º, alínea "b" e § 3º, do Código Penal e ainda porque é o único que se ajusta e convém ao acusado pela manifesta periculosidade e insolente menoscabo das regras que disciplinam o convívio social, pois é inegável a periculosidade e ousadia de quem se põe a praticar assaltos.

Não se pode esquecer que "O roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de violência e de intranquilidade que aflige a

sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo" (JUTACrim 88/87). Este regime é, portanto, o único compatível com esse tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seu autor.

Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontrastável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501- SP, verbis: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RTJ123/547).

Deixo de computar o período de prisão provisória do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há sequer provas do requisito objetivo.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, e para a garantia da aplicação da lei penal.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Assim, não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do Código Processual Penal, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Com a juntada aos autos, abra-se vista às partes para a devida ciência e eventual manifestação.

Comunique-se a vítima, consoante disposição legal.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA